

1501030-65.2020.8.26.0302

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Virginia Mendes Veloso Cardoso

Comarca: Jaú

Foro: Foro de Jaú

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2153554/2020 - CENTRAL POL.JUD-

JAÚ, 12069061 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2565/20/406 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2153554 -

CENTRAL POL.JUD-JAÚ

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaú

Foro de Jaú - 2ª Vara Criminal

Praça Dr. Mário Gomes Pahin, s/n, Centro, Jaú - SP - cep 17210-100

[https://tjssp-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/caiot_tjssp_jus_br/](https://tjssp-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/caiot_tjssp_jus_br/EblvwWEjDnRMnk5p5noFqgoB8zVK5_N02xZzsuw_zho74Q?e=B1ito7)

[EblvwWEjDnRMnk5p5noFqgoB8zVK5_N02xZzsuw_zho74Q?e=B1ito7](https://tjssp-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/caiot_tjssp_jus_br/ERuVtstvVYn50tPnNbEU0CyEBNiS4pM2aEOHWd-EQ3LhMZw?e=jWCzAN)

[https://tjssp-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/caiot_tjssp_jus_br/](https://tjssp-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/caiot_tjssp_jus_br/ERuVtstvVYn50tPnNbEU0CyEBNiS4pM2aEOHWd-EQ3LhMZw?e=jWCzAN)

[ERuVtstvVYn50tPnNbEU0CyEBNiS4pM2aEOHWd-EQ3LhMZw?e=jWCzAN](https://tjssp-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/caiot_tjssp_jus_br/ERuVtstvVYn50tPnNbEU0CyEBNiS4pM2aEOHWd-EQ3LhMZw?e=jWCzAN)

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1501030-65.2020.8.26.0302 - Controle 2020/000797

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2153554/2020 - CENTRAL POL.JUD-

JAÚ, 12069061 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2565/20/406 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2153554 -

CENTRAL POL.JUD-JAÚ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

NIDISLEY FERNANDO IGNACIO DE OLIVEIRA

Em 08 de junho de 2022, no horário designado, foi realizada audiência virtual, conforme disciplina estabelecida pela E. Corregedoria Geral da Justiça, sendo assegurado, antes do início da solenidade, o direito de entrevista reservada entre acusado e Defensora. Presente a MM Juíza de Direito, Dra. Ana Virgínia Mendes Veloso Cardoso, comigo, Escrevente, teve início a audiência para hoje designada no processo em questão, a qual foi realizada por meio de gravação na plataforma Microsoft Teams e anexada ao termo de audiência, conforme comunicado 1350/2020. Apregoadas as partes, constatou-se ter comparecido o Dr. Wellington Roger Neves, DD. Promotor de Justiça; a Dra. Tatiana Mendes Soares Bachega, Defensora Pública, ora defendendo o acusado NIDISLEY FERNANDO IGNACIO DE OLIVEIRA; o acusado referido; e as testemunhas Edi Nilton de Azevedo e Alexandre Batista Fiarresgo, que prestaram seus depoimentos. A MM Juíza indeferiu a oitiva de Márcio Rafael Marchiori, uma vez que sua situação se assemelha a de corréu. Após, procedeu-se ao interrogatório do acusado. Encerrada a instrução, em alegações finais, as Partes debateram oralmente, conforme gravação que segue. Em seguida, seguiu-se deliberação da MM. Juíza: "VISTOS. NIDISLEY FERNANDO IGNÁCIO DE OLIVEIRA foi denunciado pelo Ministério

Público como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, combinado com art. 61, "j"3, do CP. O acusado foi notificado e apresentou defesa prévia. A denúncia foi recebida em 30 de março de 2022. (p. 1893-1894) e o réu foi citado (p. 1939). Durante a instrução foram, duas testemunhas e interrogado o réu. Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu. A Defensora requereu a nulidade pela apreensão da droga e violação de domicílio e, subsidiariamente, a aplicação das benesses legais. É O RELATÓRIO. DECIDO. A ação é procedente. A materialidade delitiva foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, fotografias e laudo pericial, além da prova oral colhida na fase instrutória. A autoria é certa. Interrogado em juízo, o acusado admitiu que as drogas se destinavam à venda, mas alegou que os policiais entraram na residência sem sua autorização e negou ter vendido drogas a um usuário antes da abordagem. Aduziu, outrossim, que ainda não tinha comercializado os entorpecentes. Os policiais militares narraram, em síntese, que estavam em patrulhamento quando viram o acusado realizar contato com outro indivíduo (Márcio), em situação indicativa de tráfico. Márcio foi abordado na posse de uma pedra de "crack". O réu entrou no imóvel, onde havia um prato com mais pedras de "crack" fracionadas, além de dinheiro. A despeito das alegações defensivas, as provas são suficientes para comprovação do crime imputado ao réu. Os policiais afirmaram ter presenciado transação de entorpecente do acusado com outro indivíduo, abordado na posse uma pedra de "crack". Tal usuário, de nome Márcio, foi ouvido em solo policial e confirmou a compra da droga (pg. 7). Os agentes da lei apresentaram narrativas harmônicas a respeito dos fatos que antecederam o ingresso na residência e o encontro de mais entorpecentes no local. Tal dinâmica autorizava a entrada dos policiais no imóvel, pois evidenciava fundada suspeita da prática de crime permanente, corroborada pelo encontro de mais entorpecentes. Nesse sentido: "TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INVASÃO DOMICILIAR. PRISÃO EM FLAGRANTE. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. EXCEÇÃO À INVIOABILIDADE DE DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O ingresso em moradia alheia depende, para sua validade e sua regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental da privacidade. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. 2. Na espécie, que a entrada dos policiais no domicílio do paciente, ora agravante, se deu de forma lícita, tendo em vista os fatos narrados no inquérito policial e na instrução criminal, o que afasta o apontado constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental improvido." (STJ - AgRg no HC: 536355 SP 2019/0292244-8, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 19/11/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/12/2019). E não há qualquer elemento capaz de afastar as sobreditas versões, de resto corroborada, em solo policial, pelo usuário abordado. A propósito: Convém lembrar que os atos administrativos são dotados da presunção de veracidade e legalidade e, não havendo qualquer indício que possa macular esta qualidade, não é de se admitir, por simples contrariedade do sentenciado, que os depoimentos dos agentes públicos estejam eivados de ilegalidade, por um espírito emulativo ou qualquer outra causa espúria. Saliente-se que os depoimentos dos policiais valem como prova, inexistindo razão para desmerecê-los, pois, na condição de servidores públicos, no exercício de suas funções, gozam de presunção juris tantum de que agem corretamente, sobretudo quando suas afirmações são compatíveis com o conjunto probatório. Além disso, 'A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita' (STF, RTJ 68/54). (Apelação nº 0004050-23.2013.8.26.0161 - 4ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo - Relator Willian Campos - julgado em 27 de maio de 2014 - votação unânime). "PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO COM BASE NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO (....) 2. O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de

demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso. (...)” (STJ, HC 165.561/AM, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 15/02/2016). No mais, há mensagens indicativas de tráfico no celular do acusado (destaca-se, nesse sentido, as de fls. 263/267), o que também afasta a sua alegação de que ainda não havia comercializado o entorpecente adquirido para essa finalidade. E não há como acolher a tese defensiva quanto à irregularidade do laudo, pois foi assinado digitalmente pelo perito criminal que o elaborou (pg. 191) e indicou o objeto da perícia. Nesta toada, uma vez que o delito imputado ao acusado restou suficientemente demonstrado, sua condenação é medida que se impõe. Procedente a ação penal, passo a dosar a pena. Nesta primeira fase, a pena-base deve ser majorada em vista da alta potencialidade lesiva do entorpecente apreendido – “crack” – substância altamente nociva e viciante. Assim, fixo a pena-base acima do mínimo legal em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa. Na segunda fase, presente a agravante descrita no artigo 61, II, “j”, do Código Penal, tendo em vista que o delito foi perpetrado em período de calamidade pública em virtude da pandemia decorrente do COVID-19 (Decreto Legislativo nº 06/2020 e Decreto nº 64.879/2020 do Governo do Estado de São Paulo), ressaltando-se, sobre ela, a decisão do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo sobre o tema na Apelação nº 1507861-60.2020.8.26.0228, Relator Desembargador Tetsuzo Namba, julgado em 21/07/2020: “Justifica-se a aplicação da agravante mencionada, uma vez que o cometimento do crime nessas circunstâncias de calamidades públicas demonstra insensibilidade moral do agente para com a solidariedade social, visto que o período impõe o dever social de recíproca assistência. Ademais, é um período em que há maiores dificuldades de policiamento, por exemplo, e o agente aproveita-se disso para a prática de delitos”). Inviável o reconhecimento da confissão, pois parcial e qualificada. Assim, majoro a reprimenda de 1/6 para 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa. Por fim, a despeito das mensagens encontradas no celular do réu indicarem envolvimento de terceiros na venda de drogas, elas não permitem concluir com segurança a natureza de tal liame. Assim, e tendo em vista que a dúvida deve ser interpretada em favor do acusado, verifico a possibilidade de aplicação do disposto no §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, pelo que diminuo a pena do crime em 2/3, tornando-a definitivamente em 2 anos, 3 meses e 6 dias de reclusão e 226 dias-multa. Arbitro o dia-multa em seu valor mínimo, ante a ausência de comprovação de que o réu possa arcar com valor superior. Considerando os motivos desfavoráveis esposados na primeira fase e a natureza do delito em comento, fixo, nos termos do artigo 33, CP, o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena. É incabível o estabelecimento de regime mais favorável ou a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, até pelo disposto na Lei nº 8.072/90, que exige tratamento mais rigoroso para o delito aqui tratado. Por fim, a despeito das alterações promovidas pela Lei 12.736/12 no art. 387, do Código de Processo Penal, especialmente a inclusão da regra trazida no § 2º deste último dispositivo (o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade), deixo de aplicar de forma antecipada a detração penal por entender que esta lei modificadora é materialmente inconstitucional, afrontando os princípios da individualização da pena, do juiz natural e da isonomia (art. 5º, da Constituição Federal). A propósito, cabe trazer a lume os ensinamentos do Prof. César Dário Mariano

da Silva em recente artigo publicado na revista eletrônica Consultor Jurídico: “O princípio da individualização da pena está previsto no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, e dispõe que caberá à lei regular a individualização da pena. A individualização da pena desenvolve-se em três etapas: a legislativa, a judicial e a executória. (...) A nova lei fundiu em uma etapa a judiciária e a de execução das penas, uma vez que, ao proferir sentença, poderá o Juiz promover de regime o condenado sem atentar para a análise do seu mérito, de acordo com o previsto no artigo 112 da Lei de Execuções Penais, que dispõe: “A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo

diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão". Com efeito, a Lei das Execuções Penais, que é especial, contém normas que devem ser observadas para a correta individualização da pena. O condenado deverá cumprir a pena privativa de liberdade em etapas cada vez menos rigorosas até obter a liberdade, devendo, para tanto, ser observado seu mérito. Sem essa análise do merecimento para a progressão de regime, inclusive com a realização do exame criminológico quando necessário, está sendo violado o disposto no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal, que dispõe sobre a individualização da pena. A Lei a ser observada por ocasião da progressão de regime é a das Execuções Penais, que é especial e traz os requisitos necessários, que devem ser analisados pelo Juiz Natural da causa, que é o das Execuções Penais e não o prolator da sentença. Destarte, somente com o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 112 da Lei das Execuções Penais é que poderá ser deferida a progressão de regime pelo Juiz das Execuções Criminais, observado o princípio do juiz natural (art. 5º, LIII, CF), a teor do disposto no artigo 66, inciso III, alínea "b", da Lei das Execuções Penais. E se não bastassem esses argumentos, haverá situações em que pessoas condenadas exatamente às mesmas penas e pelos mesmos crimes terão tratamento totalmente diferente em situações iguais, com evidente violação ao princípio da isonomia. Assim, v.g, aquela pessoa condenada à pena privativa de liberdade e que tenha sido presa provisoriamente terá abatido o período pelo próprio Juiz da Condenação para fins de progressão, podendo ser diretamente promovida de regime sem a observância do mérito; ao passo que o condenado, que não tenha cumprido prisão provisória, deverá obter a progressão com o preenchimento dos requisitos do artigo 112 da Lei das Execuções Penais a serem analisados pelo Juiz das Execuções Criminais. Há, portanto, dois pesos e duas medidas, ou seja, pessoas sendo tratadas de forma totalmente diferente em situações iguais, violando, assim, o princípio constitucional da isonomia (art. 5º, "caput", da CF)"(<http://www.conjur.com.br/2012-dez-10/cesar-dario-lei-tornar-automatica-progressao-regime> - acesso em 17.12.2012, às 00h40min). Ressalte-se: a modificação proposta pelo legislador é capaz de gerar odiosa injustiça, na medida em que os condenados que tenham sido submetidos a custódia cautelar durante o processo (justamente porque a sua liberdade colocava em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal – art. 312, do Código de Processo Penal) seriam beneficiados em detrimento daqueles que puderam responder ao processo em liberdade, provavelmente indivíduos menos perigosos para a sociedade. E não é só. A antecipação da detração penal acarreta a supressão, no caso de réus presos cautelarmente, das regras para progressão de regime de cumprimento de pena privativa de liberdade, o que também se reflete em insustentável atentado ao princípio da isonomia. Tudo isso sem considerar a possibilidade de que o réu esteja preso em razão de prisão preventiva decretada em vários processos, quando a aplicação irrestrita do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal poderá acarretar a consideração do mesmo período de prisão cautelar para fins de detração em várias sentenças condenatórias, o que não se pode admitir. Assim sendo, por entender que o art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal viola a disciplina constitucional, deixo de aplicá-lo, o que faço com arrimo no controle de constitucionalidade difuso. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia para o fim de CONDENAR o réu NIDISLEY FERNANDO IGNÁCIO DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, à pena de 2 anos, 3 meses e 6 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 226 dias-multa, no mínimo legal, por ter praticado a conduta descrita no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06. O réu não poderá apelar em liberdade, tendo em vista que continuam presentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar, notadamente em virtude da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. Como se viu, após a prisão em flagrante do réu, foi-lhe concedida a liberdade provisória, mas ele não se mostrou merecedor de tal benefício, que foi revogado. Ademais, pelo que se verifica da certidão de pg. 1920, o réu possui um processo suspenso nos termos do art. 366, CPP, razão pela qual, aliás, deve ser oficiado ao juízo da 1 Vara Criminal local informando a detenção do acusado. Recomende-se, pois, na prisão em que se encontra. Nos termos do artigo 63 da Lei 11.343/06, declaro o perdimento do dinheiro apreendido. Custas

na forma da lei. Com o trânsito em julgado, expeça-se o necessário e archive-se. Saem intimados os participantes." NADA MAIS. A sentença foi exibida às partes para ciência. O Ministério Público informou que não deseja recorrer. O Réu e a Defensora informaram que desejam recorrer. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, _____(Caio C. T. Mazziero), Escrevente, digitei.

TERMO DE INTERROGATÓRIO

Antes da realização do interrogatório, foi assegurado o direito de entrevista reservada do(a) acusado(a) com o(a) defensor(a) (CPP, art. 185). Informado(a) pela MMA. Juíza do seu direito de permanecer em silêncio e de não responder perguntas que lhe forem formuladas (CPP, art. 186), o que não importará em confissão e não poderá ser interpretado em prejuízo da defesa (CPP, art. 186, par. único), às perguntas sobre sua qualificação, respondeu o(a) acusado(a):

Nome: NIDISLEY FERNANDO IGNACIO DE OLIVEIRA
CPF: 396.091.008-80, RG: 47506888, RJI: 214125698-09
Data De Nascimento: 02/06/1991
Filiação: mãe ALZIRA IGNACIO DE OLIVEIRA
Residência: Rua Luiz Lucio, 15, Jardim Maria Luiza IV - CEP 17213-130, Jaú-SP

Ciente da acusação passou a ser interrogado(a), de acordo com o art. 187 do CPP. Às perguntas da MMA. Juíza de Direito, respondeu: "O interrogatório foi realizado da forma acima referida". NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, _____(Caio C. T. Mazziero), Escrevente, digitei.